Base de Dictámenes

Trato directo, falta acreditación, omisión licitación pública

080806N13

FECHA DOCUMENTO
09-12-2013

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
SI

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictámenes 46746/2009, 44145/2010, 81171/2011, 46564/2011, 69865/2012, 2568/2013, 8186/2010, 39861/2013

Acción	Dictamen	Año
Aplica	046746	2009
Aplica	044145	2010
Aplica	081171	2011
Aplica	046564	2011
Aplica	069865	2012
Aplica	002568	2013
Aplica	008186	2010
Aplica	039861	2013

FUENTES LEGALES

ley 19886 art/8 lt/g dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/a dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/f ley 18575 art/9 ley 19880 art/52 res 1600/2008 contr art/5 dto 250/2004 hacie art/11

MATERIA

Sobre la falta de acreditación del fundamento del trato directo y la omisión de la licitación pública, para la contratación de la concesión del Complejo Asistencial Dr. Sótero Del Río.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 80.806 Fecha: 09-XII-2013

Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Roxana Guajardo Vidal, Presidenta de la Asociación de Profesionales de los Servicios de Salud del Hospital Sótero Del Río, en adelante APRUSS, representación que no acredita, quien denuncia que el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, en adelante SSMSO, mediante las resoluciones exentas Nos 1.047 y 1.048, ambas de 28 de abril de 2008, aprobó un trato directo con las señoras Zakiye Yusfille Abuhabda Tudela y Juana Muñoz Cáceres, para contratar la concesión de los casinos del Complejo Asistencial Dr. Sótero Del Río, en adelante, CASR.

La recurrente estima que no se habría acreditado el fundamento de la causal contenida en el artículo 8°, la letra g), de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, invocada en tales actos administrativos, haciendo presente, además, que por los montos involucrados, dicha convocatoria debió realizarse por licitación pública y encontrase afecta al trámite de toma de razón.

Por último, señala que si bien tales acuerdos fueron suscritos por una duración de 4 años, prorrogables por otra anualidad, hasta que se concluyera la construcción del nuevo complejo asistencial, ocasión en que se les pondría término y se llamaría a una licitación pública, le habrían informado que este proceso no se realizaría, sino que se celebraría un nuevo trato directo con los mismos proveedores.

Requerido su informe, el SSMSO mediante el oficio Ord N° 449, de 18 de abril de 2013, en síntesis, manifiesta que la contratación mediante trato directo se aprobó a través de las resoluciones exentas Nos 301 y 305, ambas de 10 de febrero de 2012, para no dejar sin alimentación al personal que lo requería por la naturaleza de sus funciones, haciendo presente que las citadas resoluciones exentas Nos 1.047 y 1.048, sólo se habrían emitido con la finalidad de aplicar un reajuste a los precios pactados, pero no para adjudicar por trato directo.

En cuanto a la toma de razón de las resoluciones aprobatorias de dichos contratos, el SSMSO indica que al momento de suscribirlos no tenían un monto determinado, por lo cual resultaba imposible establecer si se encontraban o no afectos a dicho control previo de legalidad, el que solo se pudo determinar una vez finalizado el año calendario, razón por la cual no fueron sometidas a dicho trámite. Finalmente, señala que se ha procedido a efectuar la correspondiente licitación pública de ambos casinos, en conformidad con lo establecido en la citada ley N° 19.886, y su reglamento, aprobado mediante el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Sobre el particular, del análisis de la normativa contenida en la citada ley N° 19.886 y su reglamento, los preceptos pertinentes de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los antecedentes recabados e indagaciones efectuadas por personal de esta Contraloría General, se desprende lo siguiente:

Se constató que mediante las resoluciones exentas Nos 1.047 y 1.048, ambas de 28 de

abril de 2008, el SSMSO aprobó por trato directo los contratos de concesión de ambos casinos del CASR -los que fueron suscritos el 26 de marzo de esa misma anualidad-, invocando la causal contemplada en el artículo 8°, la letra g), de la precitada ley N° 19.886, esto es, "Cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación directa, según los criterios o casos que señale el reglamento de esta ley", actos administrativos en los que, además, se estableció un reajuste de los precios pactados en los acuerdos firmados anteriormente con los mismos concesionarios.

No obstante, la Comisión Fiscalizadora de esta Contraloría General determinó que no se acompañaron antecedentes que permitieran fundamentar la ocurrencia de tal condición de excepción y que justificaran la omisión del llamado a una licitación pública.

A su vez, se comprobó que mediante las citadas resoluciones exentas Nos 301 y 305, de 2012, se aprobaron por trato directo los contratos de concesión de los dos casinos por un período de nueve meses, a contar del día siguiente del término de los anteriores convenios, invocándose en esta oportunidad la causal contenida en el artículo 10, N° 7, letra a), del citado reglamento, que permite "….. contratar la prórroga de un Contrato de Suministro o Servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la Entidad y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM".

Sin embargo, se pudo establecer que el SSMSO no realizó diligencias para determinar los montos a que ascenderían los respectivos contratos, para los efectos de dar cumplimiento a la normativa que regula esa materia.

Asimismo, se constató que mediante los oficios Ord. Nos 1.104 y 1.109, ambos del 3 de noviembre de 2011, el SSMSO comunicó a las concesionarias que conforme con lo establecido en la cláusula tercera del contrato, a partir del 25 de marzo de 2012 expiraban los convenios suscritos el 2008, y que debía efectuarse una licitación publica de acuerdo a la citada normativa.

No obstante lo anterior, el SSMSO mediante las resoluciones exentas Nos 343 y 367, ambas de 4 de febrero de 2013, prorrogó nuevamente dichos contratos mediante trato directo, invocando la causal del artículo 10, N° 7, letra f), del referido reglamento, que lo permite "Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza", acuerdos que fueron suscritos el 21 de enero del mismo año, con una duración de 4 meses, pese a que los convenios habían expirado el 27 de diciembre de 2012, conforme a los plazos aprobados por las citadas resoluciones Nos 301 y 305.

Al respecto, la Comisión Fiscalizadora de este Organismo de Control determinó que no se acompañaron antecedentes que permitieran acreditar fundadamente la inexistencia de otros proveedores que otorgaran la aludida seguridad y confianza, como lo indica el precepto invocado, para excluir la licitación pública.

Enseguida, se advirtió que mediante las resoluciones exentas Nos 1.788 y 1.789, ambas

Enseguida, se advirtió que mediante las resoluciones exentas N° 1.788 y 1.789, ambas de 4 de junio de 2013, el SSMSO renovó los aludidos contratos por un período de 6 meses a partir del 1° de mayo de 2013, a través de una adenda suscrita el 30 de abril del referido año, invocando la citada causal contemplada en el artículo 10, número 7, letra a), del mencionado reglamento, comprobándose que, como sucedió en la renovación efectuada el 2012, dicho fundamento no fue acreditado.

Asimismo, corresponde señalar que entre los antecedentes recabados se encuentra el oficio Ord. N° 7, de 21 de marzo de 2013, mediante el cual la asesoría jurídica del SSMSO informó al director de esa entidad que extender por tercera vez los contratos mediante el trato directo, vulneraba lo consignado en el artículo 10, del mencionado reglamento. Además, consta que por el oficio reservado N° 7, de 5 de junio del mismo año, dicha unidad asesora reiteró lo ya indicado, advirtiendo que ello podría acarrear sanciones para el jefe superior del servicio, haciendo presente que por la naturaleza de autogestionado que posee el CASR desde enero de 2010, no correspondía que el SSMSO asumiera su representación, en estas materias.

Al respecto, es útil anotar que una reiterada jurisprudencia de esta Contraloría General, ha señalado que no resulta procedente la autorización de nuevas prórrogas del contrato original, porque ello trae como consecuencia que su vigencia se extienda indefinidamente, lo que pugna con los principios de transparencia y libre concurrencia consagrados en el artículo 9° de la citada ley N° 18.575, y lo dispuesto sobre el particular en la mencionada ley N° 19.886 (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 46.746, de 2009, 44.145, de 2010, 81.171, de 2011, de esta Entidad Fiscalizadora).

Asimismo, es útil anotar, que cualquiera sea la causal que se invoque para un trato directo, no basta para fundamentarlo la sola referencia a disposiciones legales y reglamentarias, sino que, dado el carácter excepcional de esta modalidad, se requiere la demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea de todos los elementos que configuran las hipótesis contempladas en la normativa cuya aplicación se pretende (aplica criterio contenido en dictámenes Nos 46.564, de 2011 y 69.865, de 2012, de esta Contraloría General).

Enseguida, se debe precisar que no corresponde que la emisión de las citadas resoluciones exentas Nos 301 y 305, de 2012, tengan una fecha anterior a los contratos que aprueban por trato directo, toda vez que ello implica una vulneración del principio de irretroactividad de los actos de la Administración, consagrado en el artículo 52 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 2.568, de 2013 y 8.186 de 2010, ambos de este Órgano de Control).

Ahora bien, respecto de lo manifestado por el SSMSO, en orden a que no sometió al trámite de toma de razón los actos administrativos que aprobaron los contratos de concesión de los referidos casinos, aduciendo que no era posible establecer el monto de los mismos, corresponde señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la resolución Nº 1.600, de 2008, de este Organismo de Control, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, en los convenios de cuantía indeterminada se estará al gasto estimado por el servicio conforme a parámetros objetivos, cuyos antecedentes estarán a disposición de la Contraloría General, razón por la que no resulta procedente aceptar dicha argumentación para justificar esa omisión.

argumentación para justificar esa omisión.

En ese mismo orden de ideas, en relación con la observación contenida en el párrafo anterior, es dable hacer presente que tampoco se cumplió el artículo 11 del citado reglamento, por cuanto cada entidad es responsable de establecer el monto posible del servicio que requiere, para los efectos de determinar la modalidad de contratación que corresponde, y si ello no es factible, deberá efectuar una licitación pública a fin de asegurar el cumplimiento de la mencionada ley de compras públicas.

Por último, en relación con el proceso de licitación aludido en el citado oficio Ord. N° 449, de 2013, del SSMSO, el cual se habría efectuado para la contratación de la concesión de ambos casinos, corresponde indicar que con fecha 6 de mayo del año en curso, fueron remitidas a esta Contraloría General las bases de licitación pública para la prestación del servicio de alimentación, las que fueron aprobadas por la resolución N° 372, de 2013, de esa entidad, cuyo acto administrativo fue representado por este Organismo de Control mediante el oficio N° 39.861, de la misma anualidad, absteniéndose de dar curso al documento, por cuanto no se ajustaba a derecho.

En consecuencia, las autoridades correspondientes deberán elaborar las respectivas bases de licitación, atendiendo lo indicado por esta Contraloría General, y llevar a cabo a la brevedad el proceso de licitación pública de conformidad con lo establecido en la citada ley N° 19.886, y el mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo que deberá ser informado a esta Contraloría General.

No obstante lo anterior, esta Entidad Fiscalizadora procederá a instruir un sumario administrativo en el SSMSO a fin de determinar los hechos y eventuales responsabilidades administrativas por las sucesivas prórrogas de los contratos para la concesión de los casinos del CASR, bajo la modalidad de trato directo, entre los años 2008 y 2013, toda vez que de los antecedentes recabados aparece una eventual vulneración del ordenamiento jurídico que regula la materia, como se expresa en el presente informe.

Transcríbase a doña Roxana Guajardo Vidal, al Complejo Asistencial Dr. Sótero Del Río y a la Unidad de Sumarios de la Fiscalía de la Contraloría General de la República.

Saluda atentamente a Ud.,

Ramiro Mendoza Zúñiga

Contralor General de la República

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS